

FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 47, C.P. impugnava dinanzi al Tribunale di Roma il licenziamento per giusta causa intimatole il 29 gennaio 2016 dalla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia chiedendo che ne fosse accertata l'illegittimità e fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, e sue successive modificazioni. All'esito della fase sommaria il Tribunale rigettava il ricorso. In sede di opposizione veniva invece dichiarata l'illegittimità del recesso e disposta la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. 2. In seguito all'accertamento della diffusione di un virus nella rete aziendale l'amministrazione del sistema informatico della Fondazione aveva eseguito un accesso sul computer della lavoratrice, appurando che nella cartella di download del disco fisso della C. era presente un file scaricato che aveva propagato il virus che, partito dal computer aziendale in uso alla lavoratrice, aveva iniziato a propagarsi nella rete della Fondazione, criptando i files all'interno di vari dischi di rete, rendendo gli stessi illeggibili e quindi inutilizzabili. In occasione dell'intervento venivano in rilievo numerosi accessi – da parte della lavoratrice a siti che all'evidenza erano stati visitati per ragioni private, per un tempo lungo, tale da integrare una sostanziale interruzione della prestazione lavorativa. 3. Con lettera del 30.11.2015 alla C. veniva contestato, per il periodo 16.10.2015-16.11.2015: a) L'impiego di mezzi informatici messi a disposizione dal datore di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa a soli fini privati ed in violazione delle disposizioni impartite in ordine all'utilizzo degli stessi nonché dei più elementari doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'esecuzione della prestazione; b) la sostanziale interruzione in tutto il periodo di riferimento della prestazione lavorativa, visti tempi e quantità di navigazione per fini privati;

23. Sicché la disciplina dei controlli in questione è stata ricostruita mediante il richiamo ai principi di buona fede e correttezza (cfr. Cass. 27 maggio 2015, n. 10955, in motivazione, secondo cui deve restare ferma “la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa della organizzazione produttiva aziendale deve temperarsi, e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale”, di proporzionalità e pertinenza (cfr., sulla proporzionalità: Cass. 18 luglio 2017, n. 17723 secondo cui: “Sono invasivi i controlli cd. difensivi, sotto l’aspetto temporale, eccedenti i limiti della adeguatezza e proporzionalità e, sotto il profilo sostanziale, indebitamente ricadenti sugli aspetti privati e personali estranei all’oggetto e al fine dell’indagine”.; sulla pertinenza: Cass. 10 novembre 2017, n. 26682, in motivazione, secondo cui: “Pertanto, considerato che (...) il controllo era del tutto svincolato dall’attività lavorativa ed era stato effettuato per verificare se la strumentazione aziendale in dotazione fosse stata utilizzata per la perpetrazione di illeciti; che esso, al di fuori di una verifica preventiva a distanza dell’attività dei lavoratori, era stato occasionato da una anomalia di sistema tale da ingenerare il ragionevole sospetto dell’esistenza di condotte vietate e, quindi, giustificato dal motivo legittimo di tutelare il buon funzionamento dell’impresa nonché i dipendenti che vi lavorano, anche al fine di evitare di esporre l’azienda a responsabilità derivanti da attività illecite compiute in danno di terzi;

29. Ritiene la Corte che possa soccorrere in questo contesto la distinzione tra i “controlli difensivi” in senso lato e quelli in senso stretto. 30. Si è osservato che la giurisprudenza ammissiva dei “controlli difensivi” nella vigenza del vecchio testo dell’art. 4 St. lav, e quindi della legittimità del controllo anche in assenza del preventivo accordo sindacale o dell’autorizzazione amministrativa, dato che oggetto del controllo sarebbe stata non già l’attività lavorativa, bensì l’illecito commesso durante la prestazione lavorativa, derivava da quella che ammette, ai sensi dell’art. 3 St. lav., i controlli occulti tramite agenzie investigative diretti ad accertare condotte penalmente rilevanti dei lavoratori in occasione della prestazione (Cass., 22 maggio 2017, n. 12810; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25674; Cass., 4 marzo 2014, n. 4984). Se ne è tratta la conclusione che questa tesi sembra difficilmente armonizzabile con la disciplina dei controlli tecnologici contenuta nell’art. 4 proprio per le modalità di funzionamento di tali controlli. A differenza di un incarico ad un’agenzia investigativa, che può essere limitato ai soli accertamenti necessari ad verificare l’eventuale illecito del singolo dipendente ed essere ritenuto legittimo proprio perché così circoscritto, l’impiego di controlli tecnologici attraverso un sistema informatico che tenga traccia di tutti i dati relativi all’attività di lavoro svolta dall’insieme dei dipendenti sarebbe privo di ogni selettività e non sarebbe ammissibile, perché non orientato specificamente sull’attività illecita, ma in modo indifferenziato sulle prestazioni rese da tutti i lavoratori.

31. Occorre perciò distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro. 32. Si può ritenere che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi, all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4. 33. In effetti, come è stato osservato, l'istituzionalizzazione della procedura richiesta dall'art. 4 per l'installazione dell'impianto di controllo sarebbe coerente con la necessità di consentire un controllo sindacale, e, nel caso, amministrativo, su scelte che riguardano l'organizzazione dell'impresa; meno senso avrebbe l'applicazione della stessa procedura anche nel caso di eventi straordinari ed eccezionali costituiti dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti di un singolo lavoratore. 34. Questa soluzione è stata accolta da parte della giurisprudenza di merito, ad esempio dal Tribunale di Roma con la sentenza 24 marzo 2017, in *Diritto delle relazioni industriali* 2018, II, 265, secondo cui "E' legittimo il controllo c.d. difensivo del datore di lavoro sulle strutture informatiche aziendali in uso al lavoratore, a condizione che esso sia occasionato dalla necessità indifferibile di accertare lo stato dei fatti a fronte del sospetto di un comportamento illecito e che detto controllo prescinda dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa essendo, invece, diretto ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti".

35. Inoltre, la tesi della sopravvivenza dei “controlli difensivi”, sotto il profilo della sua compatibilità con la tutela della riservatezza di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, trova conforto nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che, in particolare nella sentenza di Grande Camera del 17 ottobre 2019, nel caso *López Ribalda e altri c. Spagna*. Si trattava di una fattispecie nella quale il gestore di un supermercato, dopo aver riscontrato discrepanze tra le scorte di magazzino e gli incassi di fine giornata, e sospettando che ciò dipendesse da illecite condotte appropriative di beni e/o denaro aziendale poste in essere da uno o più dipendenti, aveva installato all'interno del negozio dei dispositivi di videoripresa all'insaputa dei lavoratori, in posizione utile alla sorveglianza generalizzata ed indistinta di tutto il personale di volta in volta addetto al bancone di cassa, in tal modo appurando che le condotte sospettate si verificavano effettivamente. La Corte Europea ha ritenuto la legittimità dell'iniziativa datoriale, in quanto proporzionata rispetto al fine (in sé legittimo) di tutelare l'interesse organizzativo-patrimoniale del datore di lavoro, ritenendo quindi che le corti nazionali avessero correttamente valutato che le misure adottate a tutela della privacy dei ricorrenti erano appropriate. La Corte Europea ha osservato che: “(...) se non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l'installazione di strumenti occulti di videosorveglianza, tuttavia l'esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti connotati da gravità e la prefigurazione dell'entità dei danni economici che possono derivarne, così come avvenuto nel caso concreto, possono costituire giustificazione legittimante di peso sufficiente grave. (traduzione non ufficiale)”.

39. Non va infatti dimenticato che, nel caso *Barbulescu c. Romania*, sentenza della Grande Camera del 5 settembre 2017, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, chiamata a pronunciarsi – in relazione al detto art. 8 – con riguardo ad una vicenda in cui un datore di lavoro aveva sottoposto a controllo il software aziendale Yahoo Messenger in uso al lavoratore, onde verificarne un indebito utilizzo, ha fornito una interpretazione estensiva del concetto di “vita privata”, tanto da includervi la “vita professionale”, così ritenendo che lo Stato rumeno avesse tenuto un comportamento non conforme alle garanzie accordate dalla norma della Convenzione, per avere le Corti nazionali ommesso di accertare se il lavoratore avesse ricevuto una preventiva informazione dal suo datore di lavoro della possibilità che le sue comunicazioni su Yahoo Messenger potessero essere controllate; inoltre, per non avere valutato se il lavoratore medesimo fosse stato posto a conoscenza della natura e della estensione del controllo o del grado di intrusione nella vita e nella corrispondenza privata; infine, per non avere accertato le specifiche ragioni che giustificavano l'adozione di dette misure di controllo e se il datore di lavoro avrebbe potuto utilizzare misure meno intrusive, né se l'accesso al contenuto delle comunicazioni fosse stato compiuto senza che il lavoratore ne avesse consapevolezza. 40. Inoltre, e il punto è particolarmente rilevante nel caso in esame, per essere in ipotesi legittimo, il controllo “difensivo in senso stretto” dovrebbe quindi essere mirato, nonché attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, sicché non avrebbe ad oggetto l'attività – in senso tecnico – del lavoratore medesimo. Il che è sostanzialmente in linea con gli ultimi approdi della giurisprudenza di questa Corte, più sopra richiamati, in materia di “controlli difensivi” nella vigenza della superata disciplina.

41. Occorre però chiarire cosa si intenda per tale controllo. Esso infatti non dovrebbe riferirsi all'esame ed all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St.lav., poiché, in tal modo opinando, l'area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura, con conseguente annientamento della valenza delle predette prescrizioni.

42. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull'esame ed analisi di quei dati. 43. In tal caso, il controllo non sembra potersi ritenere effettuato ex post, poiché esso ha inizio con la raccolta delle informazioni; quella che viene effettuata ex post è solo una attività successiva di lettura ed analisi che non ha, a tal fine, una sua autonoma rilevanza. 44. Può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni. 45. Facendo il classico esempio dei dati di traffico contenuti nel browser del pc in uso al dipendente, potrà parlarsi di controllo ex post solo in relazione a quelli raccolti dopo l'insorgenza del sospetto di avvenuta commissione di illeciti ad opera del dipendente, non in relazione a quelli già registrati. Applicazione dei principi suesposti alla fattispecie in esame 46. Così ricostruito il quadro entro il quale i "controlli difensivi" tecnologici possono considerarsi ancora legittimi dopo la modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, si deve rilevare che la sentenza impugnata, nel ritenere l'esorbitanza della fattispecie litigiosa dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ha osservato che il controllo sul computer aziendale in uso alla C. è stato indotto dalla necessità di verificare l'origine del virus che aveva infettato il sistema informatico della Fondazione criptando vari documenti e cartelle condivise, e di risolvere il problema;

47. Se la statuizione della sentenza impugnata circa la serietà del sospetto di attività illecita indotto dalla scoperta del virus e dei danni da questo provocati può dirsi conforme alla necessità dell'accertamento del requisito del "fondato sospetto" della commissione di un illecito che i principi sopra ricostruiti assumono come presupposto della legittimità dei "controlli difensivi", è evidente come sia mancata ogni indagine nella stessa decisione volta a stabilire se i dati informatici rilevanti, utilizzati poi in sede disciplinare, fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del fondato sospetto, in violazione dei principi esposti. E' pure mancata ogni valutazione circa il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. 48. Come si è osservato, il controllo ex post non può riferirsi all'esame ed all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St.lav. prima dell'insorgere del "fondato sospetto", poiché, in tal modo opinando, l'area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura, con conseguente annientamento della valenza delle predette prescrizioni. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull'esame ed analisi di quei dati. 49. Avendo ritenuto la fattispecie inquadrabile nei "controlli difensivi", ritenuti compatibili con la nuova formulazione dell'art. 4 Statuto dei lavoratori, la Corte territoriale non ha poi verificato la compatibilità del comportamento datoriale, e quindi della utilizzabilità dei dati informatici raccolti a fini disciplinari, con quest'ultima disposizione.

50. Il motivo in esame, anche se la Corte non ne condivide l'impostazione di fondo, volta ad escludere la sopravvivenza della legittimità dei "controlli difensivi" tecnologici, va dunque accolto per quanto di ragione, cioè in quanto esso evidenzia l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei presupposti della legittimità del "controllo difensivo" posto in essere dal datore di lavoro in assenza della verifica se esso avesse ad oggetto esclusivamente dati informatici raccolti successivamente all'insorgere del "fondato sospetto".

20. Il terzo presupposto era che i controlli fossero stati disposti ex post, ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa; la sussistenza di tale presupposto offre plausibile attestazione della veridicità dell'intento datoriale, che, diversamente, non sarebbe, quale elemento facente parte della sfera interna del datore, agevolmente sindacabile (Cfr., al riguardo, Cass., 5 ottobre 2016, n. 19922, che ha ritenuto illegittimo il controllo effettuato mediante GPS installato sulle vetture in uso ai lavoratori, in quanto predisposto ex ante ed in via generale ben prima che si potessero avere sospetti su una eventuale violazione da parte del lavoratore licenziato. 21. Tale presupposto era però da considerare come eventuale, poiché ritenuto, per lo più, dalla giurisprudenza un fattore avente funzione meramente confermativa della effettività del controllo difensivo; pertanto esso poteva mancare, essendo sufficiente il mero sospetto circa l'esecuzione di illeciti, quale ulteriore requisito di legittimità del controllo difensivo, senza che la natura difensiva del controllo venisse in astratto meno (salvo il problema di accertare, per altre vie, la esclusiva destinazione di esso all'accertamento di determinati illeciti; cfr., mutatis mutandis, Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590). 22. Sebbene i "controlli difensivi" fossero sottratti all'area di operatività dell'originaria versione dell'art. 4, comma 2, St. lav., era chiaro nella giurisprudenza che essi non potevano comunque essere esercitati liberamente dal datore di lavoro al di fuori di regole di civiltà e di criteri ragionevoli volti a garantire, con l'impiego di determinati accorgimenti e cautele, un adeguato bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia della dignità e riservatezza del dipendente e quelle di protezione, da parte del datore di lavoro, dei beni (in senso lato) aziendali.